

1500704-75.2022.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... 33, § 4º, e quanto ao regime inicial. 1. Tráfico privilegiado. Cabimento.

Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, já que o réu é primário, não se dedica à atividade criminosa e não integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Atos infracionais que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500704-75.2022.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500704-75.2022.8.26.0063

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYKY HERCULANO DA COSTA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de KAYKY HERCULANO DA COSTA, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 04 de julho de 2022, às 20h40min, na Rua Luís Conde, n. 266, Vila Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Igarapu do Tietê, Comarca de Barra Bonita, o acusado trouxe consigo, para fins de tráfico, 93 porções de crack, com peso aproximado de 24,9 gramas, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso aproximado de 11,11 gramas, e 195 porções de cocaína, com peso aproximado de 156,78 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando visualizaram o acusado, sendo certo que este, ao notar a aproximação da viatura, dispensou uma sacola plástica que trazia consigo. Nessas condições, os policiais militares decidiram pela abordagem do acusado, oportunidade na qual apreenderam, no bolso de sua bermuda, 93 porções de crack, no formato de pequenas pedras, e 05 porções de cocaína, acondicionadas em pinos plásticos. Na sequência, os policiais localizaram a sacola plástica que havia sido dispensada por Kayky e, dentro dela, apreenderam mais 195 porções de cocaína, também

acondicionadas em pinos plásticos.

Auto de prisão em flagrante delito às fls. 01/03.

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 46/48).

Devidamente notificado (fl. 91), o Réu apresentou defesa prévia à fl. 89.

Recebida a denúncia em 28 de setembro de 2022 (fls. 95/96), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o Réu.

Em alegações finais, o Ministério Público e a defesa se manifestaram oralmente.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelos termos de depoimento (fls. 04/05 e 06/07), pelo termo de interrogatório (fl. 08), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição/apreensão (fl. 17), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 19/22), pelas fotografias (fls. 33/37), pelo laudo definitivo de entorpecentes (fls. 78/82), bem como pela prova oral colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha André Luiz Pavan dos Santos, policial militar, em sede policial disse que realizavam patrulhamento ostensivo/preventivo pela cidade de Igarapu do Tietê junto a Vila Nossa Senhora Aparecida e tinham conhecimento de que o indivíduo conhecido por "Kayky" estava movimentando o tráfico de drogas no local. Assim que os Policiais adentraram na Rua Abílio Perassoli cruzamento com Francisco Abile, visualizaram um indivíduo que ao notar a presença policial jogou ao chão uma sacola plástica que trazia consigo. Ao ser abordado, o mesmo foi identificado por Kayky Herculano da Costa e ao ser revistado, foi localizado em seu bolso 93 (noventa e três) pedras de material similar a "crack" bem como cinco eppendorfs contendo no seu interior, material em pó aparentando ser cocaína. Com ele ainda foi localizado R\$ 255,00 reais em espécie. Os policiais retornaram ao local onde Kayky foi visualizado dispensando a sacola plástica, sendo localizado mais 195 (cento e noventa e cinco) eppendorfs plásticos contendo no interior material em pó branco aparentando cocaína. Ao ser questionado, Kayky confessou a posse e propriedade das drogas localizadas. Diante disso, foi dado voz de prisão em flagrante delito sendo a ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia em Jaú (fls. 04/05).

Ouvido em juízo, disse que estava patrulhando por Igarapu, e foi passado o local e a pessoa de kayky como envolvido com tráfico, essas informações foram passadas pelas equipes da cidade, localizado, ele demonstrou nervosismo e jogou uma sacola em um terreno, saindo caminhando em passo largo, foi abordado, em consigo tinha 5 porções de cocaína, algumas de crack e 255 reais em dinheiro. Enquanto faziam a abordagem mantiveram contato visual com a sacola, nela acharam quase 200 eppendorfs de cocaína. Kayky estava sozinho. No momento assumiu a propriedade das drogas e a traficância. Ele não resistiu a prisão. Com kayky não havia nenhum petrecho para uso.

No mesmo sentido, a testemunha Audrin de Almeida Camargo, também policial militar, em sede policial disse que junto de seu parceiro de farda ora condutor patrulhavam pela cidade de Igarapu do Tietê, mais precisamente pela Vila Nossa Senhora Aparecida, sendo conhecedores de que o indivíduo conhecido por apenas "Kayky" estava movimentando o tráfico de drogas no local. Assim que os Policiais adentraram na Rua Abílio Perassoli x Francisco Abile, visualizaram um indivíduo que ao notar a presença policial jogou ao chão uma sacola plástica que trazia consigo. Ao ser abordado, foi identificado por Kayky Herculano da Costa, sendo que ao ser revistado, foi localizado em seu bolso 93 pedras de material similar a "crack" bem como cinco eppendorfs contendo no seu interior, material em pó aparentando ser cocaína. Com ele ainda foi localizado R\$ 255,00 reais em espécie. Os policiais retornaram ao local onde Kayky foi visualizado dispensando a sacola plástica, sendo encontrados 195 (cento e noventa e cinco) eppendorfs plásticos contendo no interior material em pó branco aparentando cocaína, idênticos aos cinco encontrados no bolso de Kayky. Ao ser questionado, Kayky confessou a posse e propriedade das drogas localizadas. Diante disso, foi dado voz de prisão em flagrante delito sendo a

ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia em Jaú (fls. 06/07).

Ouvido em juízo, disse que é da força tática e patrulha mais em Jaú, no dia foram a igaraçu e em informações com a equipe de lá, foi relatado o ponto de drogas, mencionando a pessoa de Kayky e suas características. Foram até o bairro e entrando na rua Perassoli viram Kayky que logo dispensou a sacola em um terreno baldio saindo rapidamente. De imediato fizeram busca pessoal, com ele havia crack e cocaína, além de 255 reais. Depois da abordagem foram buscar a sacola que tinha mais 195 pinos idênticos aos que tinha consigo. Ele confessou o tráfico. Kayky estava sozinho, ao que se recorda. Ele foi abordado há meio quarteirão do local que dispensou a sacola.

O Réu Kayky Herculano da Costa, em sede policial declarou que se chama Kayky Herculano da Costa. Que tem 19 anos de idade. Que já foi apreendido quando menor pelo crime de tráfico e furto. Que sua família está ciente de sua prisão. Que não tem advogado constituído. Que em relação aos fatos tem a dizer: Que as drogas localizadas consigo não são de sua propriedade. Que nega ter drogas no bolso. Que em seu bolso tinha a importância de R\$ 250,00 reais que é oriundo de seu serviço de ajudante de soldador. Que não tem nenhum machucado e não teve nenhum problema com os Policiais Militares (fl. 08).

Em seu interrogatório, o Réu esclareceu que os policiais lhe viram na rua com a sua esposa, foi abordado, não tinha droga consigo, os policiais entraram em uma casa onde é feito o uso de drogas, nega que vendesse drogas, não assumiu a propriedade das drogas. Não conhecia os policiais. Sabe que a droga estava dentro de uma casa ali perto de si, não viu se tinha alguém na casa. Tem um filho que nasceu quando estava preso, quer uma oportunidade para mudar de vida, tem família e esposa. Quer arrumar um serviço, sofreu muito na cadeia.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com as drogas apreendidas. Sobre essa questão, há o firme depoimento dos policiais de que em revista pessoal, localizaram as drogas escondidas no bolso da bermuda do acusado, além da sacola plástica com drogas, que havia sido dispensada pelo réu.

O depoimento de policial, como se sabe, goza de presunção de veracidade, sobretudo quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar, justamente como na hipótese vertente. Presume-se a lisura do agente público, pois investido no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Bis in idem - Inexistência - Regime prisional fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1500492-93.2019.8.26.0569; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021).

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra do servidor público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

É importante consignar que, além da comprovação da materialidade e da autoria do fato, necessário analisar a responsabilidade criminal do denunciado, no que se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto pelo art. 52, inciso I, da Lei n. 11.343/03, que enumera as seguintes circunstâncias a

serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente, a fim de que possa distinguir a aquisição de droga para uso ou para o tráfico.

No mesmo sentido, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, contempla alguns parâmetros para se determinar se a droga se destinava ao uso pessoal do agente.

Destarte, dispõe o dispositivo em comento que: Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Assim, dúvidas não pairam sobre a apreensão das drogas e sua titularidade, sendo certo que, nas circunstâncias em que encontradas as substâncias ilícitas e sua quantidade, resulta indubitosa a conclusão de que não se destinavam tão somente ao uso pessoal do réu. Ademais, o testemunho dos policiais foram uníssomos no sentido de que ao realizarem patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, visualizaram o acusado, e este, ao notar a presença dos policiais, dispensou uma sacola plástica que trazia consigo. Que ao ser abordado, foi localizado em seu bolso parte dos entorpecentes; e que ao retornarem no local onde Kayky havia dispensado a sacola, foram localizados mais entorpecentes. Segundo os militares, ao ser questionado sobre as drogas, o acusado confessou a propriedade, embora em sede policial tenha negado os fatos. Além disso, os policiais afirmaram que já tinham conhecimento de que um indivíduo conhecido como "Kayky" estava movimentando o tráfico de drogas no local.

Dessa forma, embora o réu tenha negado a propriedade das drogas e o propósito de tráfico, sua versão não convence. A conduta do acusado de dispensar a sacola plástica que carregava consigo, tentando se desfazer dos entorpecentes e a enorme quantidade de drogas, em plena via pública, totalmente incompatível com eventual consumo, indicam que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico. Friso que o réu possuía dinheiro (R\$ 255,00) em notas diversas, cuja origem lícita não foi comprovada. Dessa forma, as circunstâncias do flagrante, a quantidade e natureza das drogas apreendidas com o acusado, bem como os depoimentos colhidos em juízo indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

Dessa forma, impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu trazia consigo droga para comercializar a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Ainda, ressalto que conforme Estudo Técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei n. 11.343/2006, do MPPR disponível em (https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf) a quantidade compatível com o uso diário de cocaína é em média 3,8 gramas por dia, crack é de até 15 pedras por dia (entre 11 e 16), sendo que cada pedra varia de 0,1 a 1,5 gramas e de maconha é de em média 2,5 gramas, assim, as quantias e em especial, a variedade apreendida nos autos indicam a mercancia e não o uso.

Comprovado, assim, o agir típico, em sua materialidade e autoria.

O fato imputado ao Réu também é antijurídico, vez que não restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP. Ele também é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhes eram exigidas condutas diversas das que exerceu. Presente, assim, a sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Inexistem qualificadoras ou privilégios a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Aplica-se ainda a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades

criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

Na espécie, o Réu é primário e de bons antecedentes, uma vez que, com exceção deste processo, não teve nenhuma condenação transitada em julgado contra si (fl. 38). Considerando a menoridade relativa e a grande quantidade de drogas que levava consigo, bem assim que não há indicação de que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, entendo que é cabível a redução do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Esclareço que suas passagens infracionais (fls. 39/41) não podem afastar a causa de diminuição de pena, a um, porque não se referem a crimes propriamente ditos, a dois, por não revelarem dedicação atual criminosa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, § 4º, da Lei 13.343/06. Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público quanto à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, e quanto ao regime inicial. 1. Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, já que o réu é primário, não se dedica à atividade criminosa e não integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Atos infracionais que não caracterizam reincidência e não podem ser valorados negativamente a título de antecedentes. Precedentes do STF e do STJ. Quantidade da droga apreendida, ademais, que não é alta a justificar a diminuição do quantum de redução da pena. 2. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15048245820198260196 SP 1504824-58.2019.8.26.0196, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 28/05/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Quanto à fração de pena a ser aplicada, o vetor da quantidade, ainda que não afaste a causa de diminuição, pode ser utilizado como critério para aferição de como irá incidir. Consigno que neste processo foi apreendida pouco mais de 50 gramas líquidas de substância entorpecente, que se de um lado, é considerável em relação à comarca, de outro não é tamanha que implique em automática vinculação do acusado com organização criminosa: 25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 131, Compilado Lei de Drogas, Enunciado 25).

Assim a fração de diminuição de pena deve ser aplicada em seu patamar intermediário (1/2), pois demonstram que não é a primeira incursão ilícita do réu e a quantidade de drogas é considerável.

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, caput e §4º, da LD.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e possui bons antecedentes (fl. 38). A quantidade de drogas (15 gramas líquidas de crack, e 40 gramas líquidas de cocaína) é expressiva, porém será utilizada para abalisar a causa de diminuição de pena na terceira fase.

Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravante e se verifica a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do CP) – eis que o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos quando dos fatos narrados na denúncia. Dessa forma, observado o disposto na Súmula nº 231, STJ, fixo a pena provisória em seu mínimo legal, restando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Conforme exposto acima, há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em seu percentual de 1/2, assim, a pena definitiva é reduzida a 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90.

Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 CP, e do art. 42, Lei nº

11.343/06, o Réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor do Conselho da Comunidade desta Comarca, e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP – à razão de uma hora por dia de condenação, sem prejuízo à normal jornada de trabalho do Réu.

Incabível, tendo em vista a disposição contida no art. 77, III, CP.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória, com fulcro no art. 383 do CPP, para condenar o Réu KAYKY HERCULANO DA COSTA como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em penas restritivas de direitos, e 250 dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Revogo a prisão preventiva do réu, porque o regime fixado e a substituição da pena são incompatíveis com a custódia cautelar (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP), conforme precedentes dos Tribunais Superiores (STF, HC 167681 AgR, Relator(a): EDSO FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020; STJ, HC 467.949/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, ao IIRG;
- b) intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- c) expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- d) tendo em vista que a Lei nº 12.961/2014, que revogou o art. 58, § 1º, Lei nº 11.343/06 e passou a determinar a destruição da droga, por meio de incineração, quando do recebimento do flagrante (art. 50, § 3º, Lei nº 11.343/06, com a nova redação), só entrou em vigor em 04 de abril de 2014, após o flagrante, portanto, permaneço determinando a destruição da droga, guardando-se pequena amostra para contraprova;
- e) como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP);
- f) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
- g) expeça-se a certidão de honorários.

Condeno em custas, porém, desde já, concedo assistência judiciária gratuita por ser representado pela defensoria e diante do relatado em seu interrogatório.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumram-se as diligências necessárias e, oportunamente, arquivem-se.

Barra Bonita, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA